

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

[기출][2024-1-2]추가징수 처분에 대한 취소소송 제기 시 법원의 일부취소판결 가능성 여부

《[문제1] 甲은 X주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아휴직급여를 Y지방고용노동청 Z지청장(이하 'A'라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024. 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제70조 제2항에서 정한 '육아휴직이 끝난 날 이후 12개월'이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50점)

(물음2) 甲은 소송의 계속 중에 조정이 성립하여 소를 취하하고 육아휴직급여의 전액을 지급받았다. 이후 甲이 육아휴직기간 중 8개월 동안 해외에서 체류하여 해당 영유아와 동거하지 아니한 사실(이는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제14조에서 정하는 육아휴직 종료 사유이다)이 적발되었다. A는 甲에게 8개월에 해당하는 육아휴직급여의 반환명령 및 그 100/100에 해당하는 추가징수를 처분하였다. 甲이 추가징수 처분이 생계를 현저히 곤란하게 하므로 위법하다는 이유로 그 취소를 구하는 행정소송을 제기하는 경우 법원이 처분의 일부를 취소할 수 있는지를 설명하시오. (20점)

- 지방공무원법 제20조의2 [행정소송과의 관계]
- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 [시간외근무수당]
- 고용보험법 시행규칙 제105조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제119조 [육아휴직 등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

<문제1의 물음2> 추가징수 처분에 대한 취소소송 제기 시 법원의 일부취소판결 가능성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 육아휴직급여를 지급받은 후 육아휴직기간 중 해외 체류로 육아휴직 종료 사유가 발생하였다는 이유로 육아휴직급여 반환명령 및 추가징수처분을 받았고, 이에 추가징수처분의 위법을 이유로 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <추가징수처분이 재량행위에 해당하는 경우 법원이 생계곤란 등의 사정을 고려하여 처분의 일부를 취소할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 추가징수 처분에 대한 법원의 일부 취소 가능 여부에 대하여 설명한다.

II. 반환명령과 추가징수의 법적 성질

1. 반환명령

- 육아휴직급여는 고용보험법에 따른 사회보험급여로, 수급요건을 충족하지 않은 상태에서 지급받은 급여는 부당이득에 해당한다. 이에 대한 반환명령은 기속행위의 성격을 가지며, 위법한 급여수급 사실이 확인되면 반드시 발령되어야 한다.

2. 추가징수

- "고용보험법 제116조 제2항"은 부정수급액의 100/100에 해당하는 추가징수를 규정하고 있는데, 이는 제재적 성격을 가지는 재량행위이다. 따라서 반환명령과 추가징수는 법적 성질상 구분되며, 각각 독립한 처분으로 볼 수 있다.

III. 재량행위와 사법심사의 한계

1. 재량행위의 통제 범위

- 법원은 재량행위의 적법성을 심사할 때, 행정청이 재량을 행사함에 있어 비례·평등 원칙 등 일반원칙을 위반하거나, 사회통념상 현저히 타당성을 잃은 경우에 한하여 재량권 일탈·남용으로 위법성을 판단할 수 있다.

2. 대법원 판례

- "대법원"은 법원은 재량행위에 대하여 그 일탈·남용 여부만을 심사할 수 있을 뿐, 제재수준이 적정한지 여부를 독자적으로 판단하여 감경 내지 변경하는 것은 허용되지 않는다고 하였다. 즉, 법원은 재량판단의 당부 자체를 대체할 권한이 없고, 오직 그 재량행위가 사회통념상 현저히 불합리하여 위법한지 여부만 심사할 수 있다.

3. 가분성 문제

- 행정처분이 가분성을 갖는 경우에는 일부 취소도 가능하지만, 재량행위의 경우 법원이 일부 취소를 통해 제재수준을 실질적으로 변경하는 것은 곧바로 재량권의 대체행사로 이어질 수 있으므로 허용되지 않는다. 따라서 반환명령과 추가징수가 법적으로 구분된다 하더라도, 법원이 추가지급분만 취소하는 것은 자칫 제재의 경중을 조절하는 결과가 될 수 있어 제한된다.

IV. 사안의 적용

1. 반환명령 부분

- 甲이 8개월 동안 영유아와 동거하지 않은 사실은 법령상 육아휴직급여 수급자격 상실 사유에 해당한다. 이에 따라 해당 기간 지급된 급여는 부정수급으로 보아 반환명령을 내린 A의 처분은 기속행위로 정당하다. 법원은 이를 취소할 수 없다.

2. 추가징수 부분

- 추가징수는 재량행위이므로, 법원은 A가 생계 곤란 사정을 고려하지 않고 기계적으로 전액을 부과한 것이 사회통념상 현저히 불합리한지 여부를 심사한다. 만약 생계 유지가 사실상 불가능할 정도의 과도한 제재로 평가될 경우, 이는 재량권 일탈·남용으로 위법하다. 그러나 법원은 그 위법성을 인정할 경우 추가징수처분 전부를 취소할 수 있을 뿐, 일부만 감액하는 방식으로 적정 수준을 새로 설정할 수는 없다. 이는 "판례"("2007두18062")가 확인한 바와 같이 법원이 재량권을 대체할 권한이 없기 때문이다.

3. 결론적 판단

- 따라서 법원은 반환명령 부분은 그대로 두되, 추가징수 전액이 사회통념상 과도하다고 인정된다면 추가징수처분 전체를 취소할 수 있다. 그러나 추가징수처분을 일부만 취소하여 추가징수액을 감경하는 방식의 판결은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 육아휴직급여 반환명령은 기속행위로서 정당하며 취소될 수 없다. 추가징수처분은 재량행위로서, 그 전액 부과가 甲의 생계 곤란 등 구체적 사정을 전혀 고려하지 않아 비례원칙에 반해 사회통념상 현저히 타당성을 잃은 경우 재량권 일탈·남용으로 위법하게 된다. 다만 법원은 "판례"("2007두18062")가 확인한 바와 같이 법원이 재량권을 대체할 권한이 없기 때문이다.

2")가 설시한 바와 같이 재량권 일탈 여부만 심사할 수 있을 뿐, 제재수준을 적정하게 감경·변경하는 권한은 없다. 따라서 법원은 반환명령은 존속시키
되, 추가징수처분 전부를 취소할 수 있을 뿐, 일부만 취소하는 것은 허용되지 않는다.